

RECURSO CÍVEL Nº 5086214-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE GUSMAO BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTOS COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral apenas no tocante à rubrica folga indenizada. Deixo de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedor, mesmo que em parte. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5086214-94.2024.4.02.5101

510014902886 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5086214-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE GUSMAO BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de não-incidência do imposto de renda sobre as verbas de **'folga indenizada', 'indenização por repouso semanal não gozado', 'abono pecuniário de férias, 'bônus' e 'prêmios'.**

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que o entendimento de que *somente rubricas cuja denominação exata fosse "folgas indenizadas"* estaria no campo da não incidência do imposto de renda diverge do posicionamento do STJ, das Turmas Recursais e da Turma Nacional de Unificação dos Juizados Federais. Dessa forma, aduz pelo recente julgado da 7ª Turma Recursal do TRF 2ª, que diz ser desnecessário que o pedido traga expressamente todas as espécies já citadas na fundamentação da Inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte Ré, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, eis que comprovada a condição de hipossuficiência.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O cerne da questão está em determinar a natureza do pagamento feito à parte autora.

Veja-se o teor do art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Os valores devidos em virtude de folgas não gozadas são de natureza indenizatória.

A lógica que se apresenta é a seguinte: estando o trabalhador à disposição do empregador no momento em que deveria estar liberado, há uma supressão de possibilidade de descanso ou de realização de atos outros importantes à sua vida. Qualquer acréscimo realizado à quantidade de tempo que o trabalhador deva permanecer no trabalho é um cerceamento de tempo que poderia ser utilizado ao arbítrio do trabalhador.

É por tal razão que é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em função de férias e/ou folgas não gozadas. A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial, ao contrário do que alega a ré em sede recursal, mas mera indenização por serviços prestados e pela supressão de possibilidades pela qual passou o autor.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/12/2007, p. 1182) (Grifei)

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, a TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, em que pesem as alegações do autor, não vislumbro que os valores recebidos a título de conversão de férias em abono pecuniário tenham sofrido a incidência do imposto de renda.

Por sua vez, a folga indenizada não se confunde com a dobra, devida aos trabalhadores em regime *off-shore* que é expressamente tratada pelo artigo 2º, da Lei 5.811/72, nos seguintes termos:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção d áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

O referido dispositivo prevê que é possível a manutenção do empregado no posto de trabalho sempre que foi imprescindível para a continuidade da operação, prevendo a lei acima em seu artigo 3º alguns direitos dentre eles o pagamento em dobro e o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados, conforme abaixo:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

*I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do **art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho**;*

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.

Analisando a redação da legislação acima, conclui-se que o momento de folga perdida pela dobra é compensada com outra folga posterior, havendo apenas um adiamento. Ante isso, os valores recebidos pela dobra tem natureza remuneratória.

Assim, em razão do trabalhador em regime *off-shore* poder ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade da empresa de continuidade do serviço operacional ou por segurança, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

Contudo, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas pagas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda e apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Desta forma, existe dupla repercussão na manutenção do marítimo no posto de trabalho: por um lado, o recebimento de verba decorrente das horas trabalhadas em dobro, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, que representa acréscimo patrimonial. Do outro, o pagamento de indenização em separado pela renúncia ao direito ao descanso, para executar o trabalho determinado pelo empregador, não incidindo imposto de renda neste último caso.

Vale ressaltar que independente da nomenclatura dada à verba pelo empregador na convenção/acordo coletivo(a) de trabalho, a mesma não se impõe ao Fisco, uma vez que as convenções particulares não são hábeis a modificar a legislação tributária, retirando a responsabilidade do contribuinte de efetuar o recolhimento do tributo, seja imposto de renda ou mesmo contribuição previdenciária, conforme dispõe o artigo 123 do CTN.

Especificamente em relação ao imposto de renda no caso em tela, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme dispõe o artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713/88.

Assim, a renda auferida pela parte autora, uma vez identificada como fato gerador de imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN, incidirá o referido tributo, independente do *nomen iuris* atribuído no contracheque ou contrato de trabalho pelo empregador.

Além disso, não há como conferir interpretação extensiva de que todas as verbas recebidas pela parte autora, a título de trabalho fora da jornada, configuram indenização, devendo ser verificadas as efetivas naturezas das mesmas, já que a legislação tributária, no casos de benefício fiscal, utiliza-se a interpretação restritiva, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.

Por derradeiro, conferir entendimento diverso ao exposto acima, é atribuir de forma absurda o papel de legislador à empresa contratante, onde ficaria a cargo desta definir o nome da verba e sua natureza, impactando conseqüentemente todo o sistema tributário nacional, que por óbvio, além de interferir na arrecadação do imposto de renda, esbarraria na incidência de outros tributos, tais como a contribuição previdenciária, gerando um colapso fiscal.

Superada a distinção de folgas e dobras, o trabalho pré-embarque também não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada.

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas sim de repouso. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 463. O enunciado sumular prevê que os valores recebidos a título de indenização por hora extra sofrem a incidência do imposto de renda.

Súmula 463

Incidirá imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Portanto, somente estarão no campo da não-incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Neste sentido, processo de nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, desta Relatoria, julgado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 20/03/2024.

Quanto à rubrica "descanso semanal remunerado não gozado", discriminado em contracheque como "DSR", com previsão no artigo 59-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-lei nº 5.452/1943), consiste em valor pago pelo empregador ao empregado em razão do exercício de trabalho durante finais de semana ou feriados, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em horário de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.

Neste contexto, em que o descanso é postergado, e não efetivamente suprimido, resta evidenciada a natureza remuneratória - e, portanto, não indenizatória da verba recebida; com efeito, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5116118-96.2023.4.02.5101, julgado em 29/05/2024, *in verbis*:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLGAS INDENIZADAS, AUXÍLIO ESCOLAR E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. CONFORMIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA QUANTO AO **DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.** (grifei)*

Neste sentido, processo de nº 5011707-93.2023.4.02.5103/RJ, da relatoria da DRa KARLA Nanci Grandó, julgado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 23/10/2024.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral apenas no tocante à rubrica ***folga indenizada***. Deixo de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, eis que vencedor, mesmo que em parte. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

5086214-94.2024.4.02.5101

510014902885 .V3